

الإثبات الإلكتروني ووسائله وحجته

مفهوم الإثبات الإلكتروني :

يقصد بالإثبات الإلكتروني : إقامة الدليل أمام القضاء على صحة الوقائع والتصرفات القانونية أو نفيها بالوسائل الإلكترونية بدلاً من الوسائل التقليدية.

من ثم يقتضي هذا النوع من الإثبات الاعتداد بالوسائل الإلكترونية بشئ أنواعها في نطاق إتمام هذه الوقائع والتصرفات أولاً، ثم الاستفادة منها في نطاق الإثبات.

وسائل الإثبات الإلكتروني :

يتم الإثبات الإلكتروني بالعديد من الوسائل في الوقت الحالي، فضلاً عن المستقبل، ويأتي في مقدمة هذه الوسائل المحررات الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي بين الناس، كوسيلة يمكن أن تتم بها التعاملات المالية وغير المالية بينهم، وكذلك الوسائل الإلكترونية الأخرى التي يمكن أن تساهم في التواصل والتعامل بين الأفراد، كالتلكس والفاكس والبريد الإلكتروني وغيرها من الوسائل التكنولوجية الحديثة. لا شك أن أهم هذه الوسائل وأوسعها انتشاراً **المحركات الإلكترونية**.

مفهوم المحركات الإلكترونية :

تباينت تشريعات المعاملات الإلكترونية وآراء شراح القانون حول بيان مفهوم المحرر الإلكتروني :

• فمنها من أطلق عليه لفظ السجل الإلكتروني أو المستند الإلكتروني كقانون المعاملات الإلكترونية الكويتي والإماراتي والسعودي.

• ومنها من أطلق عليه لفظ البيانات، كقانون التوقيع الإلكتروني المصري.

حيث عرف المشرع المصري المحرر الإلكتروني بأنه : " رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تخرج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأي وسيلة أخرى ".

يؤخذ على هذا التعريف :

• أنه يخلط بين الكتابة الإلكترونية والمحرر الإلكتروني.

• أنها تقصر المحرر الإلكتروني على ما يرد في الرسالة الإلكترونية فقط، مع إن المحرر الإلكتروني قد يكون مدوناً في سجلات الكترونية أو قاعدة بيانات الكترونية.

لذا يمكن تعريف المحرر الإلكتروني بأنه: كل واقعة أو تصرف قانوني ينشأ بإحدى وسائل التقنية الحديثة (الإلكترونية) مثل الحاسب الآلي أو الهواتف المحمولة، ويتم تداوله بطريقة الكترونية أيضاً تتم غالباً عن الشبكة العنكبوتية العالمية المعروفة بالإنترنت، ويمكن نسبته لمن صدر عنه، ويمكن استرجاعه والاطلاع على محتواه من قبل المعنيين به في أي وقت.

بناءً على ذلك يتضمن المحرر الإلكتروني شأنه في ذلك شأن المحرر التقليدي أمران أساسيان ، هما :

- الواقعة أو التصرف محل الاتفاق بين الطرفين (مضمون الكتابة الإلكترونية).
- توقيع ذوي الشأن على مضمونه (أي إمكانية نسبة مضمون الكتابة لمرسلها).

حجية المحركات الإلكترونية في تشريعات المعاملات الإلكترونية

تكاد تتفق تشريعات المعاملات الإلكترونية على الاعتراف بالكتابة الإلكترونية بصفة عامة ومقاربتها من الكتابة التقليدية وخاصة في مجال الإثبات، نتيجة لتزايد الحاجة لمثل هذا النوع من الكتابة في إتمام المعاملات المالية وغير المالية بين الناس عبر وسائل التقنية الحديثة.

بيد أن هذه التشريعات تباينت حول نطاق الاحتجاج بهذه المحركات؛ حيث يضفي البعض عليها نفس حجية وأهمية المحركات التقليدية في مجال الإثبات وغيره كمجال الانعقاد أيضاً، بينما يقصر البعض نطاق الاعتداد بهذه المحركات على مجال الإثبات فقط.

لقد نصت التشريعات العربية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية صراحة على أهمية الكتابة الإلكترونية وضرورة الاعتراف بها كوسيلة للتعبير عن الإرادة في المعاملات التجارية بصفة عامة، ومن ثم الإقرار بحجيتها في إثبات هذه المعاملات.

ففي جمهورية مصر العربية: أكد المشرع على المساواة بين الكتابة الإلكترونية والكتابة التقليدية في الحجية: حيث تنص المادة (٥) من قانون التوقيع الإلكتروني على أنه: "للكتاب الإلكترونية والمحركات الإلكترونية، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحركات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

هذا النص واضح الدلالة على تمتع المحركات الإلكترونية بذات حجية المحركات التقليدية في الإثبات.

شروط حجية المحرر الإلكتروني في الإثبات: لكي تتمتع المحركات الإلكترونية بالحجية القانونية يجب أن

تتوافر فيها شروطاً معينة تضمنتها قوانين المعاملات الإلكترونية في معظم الدول

فلقد أورد قانون التوقيع الإلكتروني المصري في المادة الثامنة منه شروطاً لحجية التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحركات الإلكترونية بصفة عامة:

حيث قررت هذه المادة حجية الإثبات بالتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية متى توافرت الشروط التالية:

أ- ارتباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره .

ب- سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني.

ت- إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني".

قد حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لتحقيق هذه الشروط في الكتابة الإلكترونية والمحركات الإلكترونية في المادة الثامنة بقولها:

"... تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحركات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية:

أ- أن يكون متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحركات الإلكترونية الرسمية أو العرفية وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحركات أو لسيطرة المعني بها.

ب- أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحركات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها.

ت- في حالة إنشاء وصدر الكتابة الإلكترونية أو المحركات الإلكترونية الرسمية أو العرفية من دون تدخل بشري، جزئي أو كلي، فإن حجيتها تكون محققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحركات".

في ضوء النصوص السابقة يشترط للاحتجاج بالمحركات الإلكترونية الشروط الآتية:

الشرط الأول: إمكانية تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحركات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ومصدر إنشائها: وذلك من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل لا يخضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك

المحركات أو المعني بها حتى لا يتم التعديل فيها متى شاء، وأن أي تعديل يمكن كشفه بسهولة، وإمكانية معرفة سيطرة منشئ هذه المحركات على الوسائط الإلكترونية المستخدمة في إنشائها.

الشرط الثاني: إمكانية الاحتفاظ بالمحرر الإلكتروني بالشكل الذي نشأ أو تم إرساله أو تسلمه عليه أو بأي طريقة يسهل بها إثبات صحة البيانات التي وردت فيه عند الإنشاء أو التسليم أو الإرسال:

أي إنه يشترط للاحتجاج بالمحرر الإلكتروني أن يتم الاحتفاظ به بما يضمن سلامته وسلامة ما تضمنه من بيانات أو معلومات على النحو الذي جاء به عند إنشائه أو إرساله أو تسلمه، بحيث لا تتعرض هذه البيانات أو المستند نفسه للهلاك أو التلف أو التغيير أو التبديل، فيظل كما هو بما يمكن الرجوع إليه في أي وقت، وإن لم يمكن حفظه بالشكل الذي جاء به والمواصفات التي كان عليها يمكن حفظه بوسيلة أخرى تضمن الاحتفاظ ببياناته ومعلوماته أي استخدام دعامة الكترونية أخرى تحفظ المرور، وبياناته كاملة دون تلف أو هلاك كالأقراص المدمجة، أو الفلاشات، وأصبح من الممكن الاحتفاظ بالمحركات الإلكترونية الآن على مواقع حفظ البيانات على الشبكة العنكبوتية العالمية (الانترنت) مثل جوجل دريف وغيرها.

الشرط الثالث: أن تكون البيانات الواردة بالمحرر الإلكتروني قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت : ومؤدى هذا الشرط ومفاده يعول على البيانات الواردة بالمحرر الإلكتروني والتي لا بد أن تكون قابلة للاحتفاظ بها وتخزينها حيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت كلما اقتضت الحاجة، كأن يكون هناك خلاف بين طرفي معاملة ما ويلجؤون إلى القضاء ويستندون إلى بعض المحررات الإلكترونية

وهنا يجب أن ننوه على أن الخصائص المادية لبعض من الدعامات الإلكترونية والتي تستخدم لحفظ المعلومات كالأقراص الممغنطة والتي تتميز بقدر كبير من الحساسية للضوء والحرارة، والتي قد تكون سبباً في سهولة تلفها مع الوقت والذي قد يكون عائقاً أمام الاحتجاج بما فيها من معلومات.

إلا أن التطور في هذا الشأن مستمر حيث ظهرت الكثير من الدعامات الإلكترونية الأكثر فاعلية وأماناً ، كالفلاشات واسطوانات (الدي في دي)، بالإضافة إلى وجود شركات متخصصة في حفظ وتخزين المعلومات الإلكترونية والتي تهتم بحفظ المعلومات وتأمينها من أي اختراق من الغير ، وكلما كانت هذه الشركات ذات كفاءة عالية في تأمين المعلومات والاحتفاظ بها كلما كانت حجية المعلومات أقوى.

الشرط الرابع: أن تدل البيانات الواردة بالمحرر الإلكتروني على هوية منشأها ومستقبلها ووقت الرسل والتسليم: أي ان البيانات الواردة بالمحرر الإلكتروني يجب أن تدل بوضوح تام على منشأ المحرر الإلكتروني ومن يستقبله وتاريخ الإرسال والاستقبال حتى تحظى بحجية قانونية، فبمقدار ما يتمتع به المرسل والمستقبل من مصداقية في المعاملات التجارية تكون قوة المحرر الإلكتروني وحجيته، وتاريخ ووقت الإرسال والاستقبال يدلان على عدم العبث بالمعلومات الواردة بالمحرر الإلكتروني أو تغييرها بعد هذا الوقت والتاريخ.

الشرط الخامس: أن يتم حفظ البيانات والمعلومات على شكل مستندات أو سجلات إلكترونية : وهذا الشرط يؤكد على أهمية حفظ المعلومات والبيانات بشكل إلكتروني حتى يسهل الرجوع إليه كلما اقتضت الحاجة، وما يتم حفظه بشكل تقليدي أو ورقي لا يعتد به ولا يحتاج بما ورد فيه من معلومات وبيانات.

متى استجمعت المحررات الإلكترونية الشروط السابقة فإنها تكتسب حجية المحررات التقليدية ويعتد بها في الإثبات سواء أكانت محررات عرفية أم رسمية.

حجية البريد الإلكتروني في الإثبات :

مفهوم البريد الإلكتروني: البريد الإلكتروني هو نظام يسمح بالتواصل بين الأشخاص وتبادل الرسائل الرقمية أو الإلكترونية والملفات والرسوم والصور وغيرها بينهم عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)؛ حيث يمكن إرسال الرسائل من المرسل إلى مستقبل أو أكثر إلكترونياً بدلاً من استخدام البريد التقليدي وهو يقوم مقام صندوق البريد العادي مع وجود اختلاف جوهري، ألا وهو أن البريد الإلكتروني يحتفظ بكافة الرسائل المرسلة سلفاً والتي تم استقبالها ، بل والتي تم إلغاؤها أيضاً، بالإضافة إلى قائمة من عناوين البريد الإلكتروني التي يتم استخدامها.

حجية البريد الإلكتروني :

واقع الأمر أن هناك خلافاً كبيراً بين الفقهاء في حجية البريد الإلكتروني ما بين مؤيد ومعارض، ولكن ما أميل إليه هو تمتع رسائل البريد الإلكتروني بالحجية في إثبات ما تتضمنه من حقوق أو التزامات، باعتبارها كتابة إلكترونية رسمية كانت أم عرفية إن توافرت فيها الشروط التي نص عليها قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٥ والتي نصت المادة الثامنة منه على : "مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية:

أ- أن يكون متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية.

ب- أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر.

ت- فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات".

حجية الفاكس والتليكس في الإثبات :

1- الفاكس : يعرف الفاكس بأنه جهاز وظيفته نقل الصور الثابتة من مكان إلى آخر عبر شبكات الهاتف. قد ذاع صيت الفاكس في بداية ظهوره بشكل كبير ثم تراجعت مكانته بعد التطور الهائل في وسائل الاتصالات بعد ظهور الحاسب الآلي والانترنت.

حجية رسائل الفاكس : اختلفت الآراء وتباينت وجهات نظر شراح القانون حول حجية الرسائل المرسلة عبر الفاكس، ولكن حسم هذا الخلاف المشرع المصري الذي اعترف بحجية الرسائل والمكاتبات المرسلة عبر الفاكس.

لقد جاء ذلك واضحاً جلياً في نص المادة الثانية عشرة من قانون التحكيم المصري والتي نصت على أنه : "يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة". من ثم فإن للرسائل والمكاتبات المرسلة بالفاكس حجيتها باعتباره محرراً مكتوباً من الطرفين، حيث أقر هذا النص صراحة حجية المحررات المكتوبة المتبادلة بين الطرفين من خلال البرقيات وغيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.

2- جهاز التاكس : هو عبارة عن جهاز للطباعة الإلكترونية، وتكون الرسائل الصادرة بخط مائل لليمين، أما الرسائل المستلمة فتكون حروفها معتدلة وبهذا يسهل التفريق بين الرسائل الصادرة والمستلمة. يمكن لأي مشترك في خدمة التليكس أن يتواصل مع أي مشترك آخر في أي مكان في العالم عن طريق رقم المشترك بطريقة تشبه إلى حد كبير التواصل عبر الهاتف، والتواصل يكون على مستوى الأفراد والهيئات والمؤسسات بقطاعها الخاص والعام.

أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يمتلكون أجهزة تليكس أو غير مشتركين في الخدمة فيمكنهم إرسال أو استقبال رسائل التليكس عن طريق المكاتب الخاصة التي توفر هذه الخدمة.

حجة رسائل التليكس : يعتبر التليكس أكثر أماناً لتوفير عناصر الإثبات من جهاز الفاكس؛ لأنه يعتبر من قبيل التعاقد بالمراسلة؛ حيث يستطيع المشترك عن طريقة التواصل مع أي مشترك آخر لديه الجهاز نفسه وإرسال إيجابه وتسلم الرد أيا كان مكان المشترك الآخر، ويتسم التواصل بالتليكس بأن لكل مشترك رقم سري خاص به. تكتسب رسائل التليكس حجيتها في مصر بمقتضى المادة الثانية عشرة من قانون التحكيم المصري والتي تنص على أنه: "يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون إتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقع الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة". حيث تقضي هذه المادة صراحة أيضاً على حجية المستندات المتبادلة بين الطرفين عن طريق البرقيات. قد اعترفت معظم التشريعات العربية بحجية رسائل التليكس بشرط وجود الأصل لدى مكتب التصدير، وإذا فقد الأصل تفقد الرسالة حجيتها وتكون مستنداً على سبيل الاستناس.

بعض التشريعات تتطلب لحجية رسائل التليكس ألا ينفي مرسل الرسالة بأنه هو الذي أرسلها أو فوض من يرسلها وإلا فلا حجية لها.

في ظل التطور الكبير في وسائل الاتصالات فإن هناك نوع آخر من رسائل التليكس يكون مزود برقم سري معلوم من الطرفين (المرسل والمستقبل) وهو ما يعطي للرسالة حجيتها؛ لأنه يثبت علم الطرفين بالرسالة ولا مجال لإنكارها.

شهادة الشهود

تمهيد : لقد كانت الشهادة في الماضي هي الدليل الغالب، إلا أنها أصبحت في الوقت الحاضر من الأدلة المقيدة؛ حيث لا يجوز الاستناد إليها إلا في إثبات بعض الوقائع القانونية دون البعض. ينقسم هذا المبحث إلى هذه المطالب :

تعريف الشهادة وأنواعها وحكمها	خصائص الشهادة وشروطها
نطاق الإثبات بشهادة الشهود	

تعريف الشهادة وأنواعها وحكمها

تعريف الشهادة :

لقد عرف بعض الفقه الشهادة « مجال الإثبات » بأنها : إخبار الشخص أمام القضاء بواقعة حدثت من غيره، ويترتب عليها حق لغيره.

بينما عرفها البعض الآخر بأنها: الإخبار في مجلس القضاء بما تحصل لدى الشاهد العلم به، بشأن الواقعة المتنازع عليها بين طرفي الخصومة.

صدور الشهادة من شخص ليس خصمًا في الدعوى أمام القضاء لإثبات حق لغيره في ذمة غيره، يميزها عن الإقرار الذي يصدر من أحد الخصوم لإثبات حق في ذمته، كما يميزها عن الادعاء الذي يصدر من أحد الخصوم لإثبات حق له.

أنواع الشهادة : الشهادة في القانون أربعة أنواع :

الشهادة السماعية	الشهادة المباشرة
الشهادة بالشهرة العامة	الشهادة بالتسامع

1- الشهادة المباشرة (الأصلية) :

الأصل في الشهادة أن تكون مباشرة، وهي التي يدلي فيها الشاهد بما يعرفه معرفة شخصية عن الواقعة المراد إثباتها، ويُحصل الشاهد معرفته الشخصية بالواقعة:

- إما لأنه رآها بعينه، كشأن من يشهد بواقعة مادية رآها، مثل حادثة سيارة أو إتلاف مال أو تسليم شيء.
- وإما لأنه سمعها بأذنه، كشأن من حضر مجلس العقد وسمع البائع يتعاقد مع المشتري.
- وإما لأنه رأى وسمع، كما لو سمع المقرض يتعاقد مع المقرض ورآه يعطيه مبلغ القرض.

2- الشهادة السماعية (الشهادة غير المباشرة) :

وهي التي يشهد فيها الشاهد بما أخبره به شخص آخر عن الواقعة محل الإثبات، كمن يشهد أنه سمع فلان من الناس يروي له حادث السيارة الذي رآه بعينه.

قد قضت محكمة النقض أن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة المباشرة، إلا أنها تعتبر بطبيعة الحال أقل من الشهادة الأصلية المباشرة، ويقدر القاضي مدى قيمتها في الإثبات.

تظهر أهمية الاستدلال بالشهادة السماعية في كشف الحقيقة، إذا كان سماع الشاهد الأصلي صار مستحيلًا لوفاته أو متعذرًا لسفره.

3- الشهادة بالتسامع :

وهي الشهادة بما يتسامعه الناس وما شاع بينهم بشأن الواقعة محل الإثبات .

تختلف الشهادة بالتسامع عن الشهادة السماعية؛ حيث :

- إن الشهادة السماعية تنصب على الواقعة المراد إثباتها بالذات ويكون النقل فيها عن شخص بعينه، ومن ثم يمكن تحري مبلغ الصديق فيها، ويتحمل صاحبها مسئولية شخصية فيما سمعه بنفسه عن غيره.
- أما الشهادة بالتسامع فصاحبها لا ينقل عن شخص معين ولا عن واقعة بالذات، ومن ثم لا تكون قابلة للتحري، ولا يتحمل صاحبها مسئولية شخصية فيما شهد به.

لما كان من العسير تحري وجه الصحة بالنسبة لهذا النوع من الشهادة، وعدم نص القانون على مدى حجيتها، فإن القضاء في مصر لا يقبل الشهادة بالتسامع في المسائل المدنية، وإن كان يقبلها في المسائل التجارية والأحوال التي يقبل فيها الإثبات بالبيئة أو بالقرائن على سبيل الاستئناس، وبكثير من الحذر والاحتياط.

4- الشهادة بالشهرة العامة :

وهي ليست شهادة بالمعنى الصحيح، بل هي ورقة مكتوبة ومحركة أمام جهة رسمية، تدون فيها وقائع معينة، يشهد بها شهود يعرفون هذه الوقائع عن طريق الشهرة العامة.

من أمثلتها : الشهادة على إعلام الورثة ، ومحضر حصر التركة ، ووقائع الميلاد والوفاة.

إن الشهادة بالشبهة العامة تنصب على معرفة الشهود للواقعة محل الإثبات معرفة شخصية، ولكن لا عن طريق محدد، وإنما عن طريق الشبهة العامة، ومن ثم تتصف بأنها شهادة جماعية، وللشهادة بالشبهة العامة قوة في الإثبات يحددها القانون في كل حالة على حدة.

حكم أداء الشهادة :

إذا أمرت المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو استجابة لطلب الخصوم إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود اظهاراً للحقيقة ، وجب على الشاهد تلبية دعوتها للحضور، وإلا حكم عليه بالغرامة المقررة في المادة (٧٨) إثبات إذا كلف بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر ، كما أن للمحكمة أن تأمر بإحضاره، فإذا حضر وجب عليه الإدلاء بشهادته، وإلا حكم عليه بالغرامة المقررة في المادة (٨٠) إثبات) ما لم يكن لامتناعه مبرراً قانونياً. يجب على الشاهد أن يقول الحقيقة، ومن ثم إذا شهد زوراً في دعوى مدنية عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويعاقب بمثل عقوبته من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً ، وإعمالاً للأحكام العامة للمسئولية التقصيرية

وقياساً على المادة (١٧) إثبات)، فإنه إذا ثبتت الشهادة الزور من جانب الشاهد بحكم جنائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالبه بالتعويض.

لأهمية الشهادة في استظهار الحقيقة أجاز المشرع في حالة ما إذا كان هناك عذر يمنع الشاهد من الحضور، أن ينتقل إليه القاضي المنتدب، أو أن تندب المحكمة أحد قضاتها إذا كان التحقيق يتم أمامها ؛ لسماع أقواله، ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكتاب.

خصائص الشهادة وشروطها

الشهادة خبر يحتمل الصدق والكذب، إلا أن احتمال الصدق أقوى من احتمال الكذب؛ حيث إن الشاهد يخلف على صدق ما يقوله، كما أنه يشهد بحق لغيره على غيره، ومن ثم لا مصلحة له في الكذب، ولكن على الرغم من ذلك فإن احتمال الكذب لا ينتفي بها انتفاء تاماً ؛ لذا اعتبرها المشرع من طرق الاثبات وجعل لها عدة خصائص واشترط لقبولها عدة شروط. ينقسم هذا المطلب إلى فرعين :

خصائص الشهادة

تتميز الشهادة كوسيلة من وسائل الإثبات بعدة خصائص :

أولاً : الشهادة حجة مقنعة وليست ملزمة للمحكمة :

فشهادة الشهود من أدلة الإثبات غير الملزمة التي ترك القانون تقدير حجيتها للمحكمة وفقاً لاقتناعها بها واطمئنانها إليها، فلا يلتزم القاضي الحكم طبقاً لها إلا إذا اقتنع بدلائلها ولو لم تكن هناك أدلة أخرى تعارضها في الدعوى

لهذا يكون للمحكمة أن تطرح أقوال الشهود لعدم اقتناعها بصدقهم، أو أن ترجح أقوال شاهد على آخر وفقاً لما تظمن إليه، أو أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد دون بعضها الآخر.

يستقل قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستخلاص ما يقتنع به منها دون رقابة عليه من محكمة النقض، طالما كان استخلاصه سائغاً، ولا خروج فيه على مدلول تلك الشهادة، ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.

ثانياً : الشهادة حجة غير قاطعة :

معنى ذلك أن ما ثبت بالشهادة يصح نفيه بشهادة أخرى أو بأي طريق آخر من طرق الإثبات، فيعتبر ما ثبت بالشهادة صحيحاً إلى أن يثبت عكسه قبل الحكم به.

لذلك نصت المادة (٦٩) من قانون الإثبات على أن: "الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق".

ثالثاً : الشهادة حجة متعدية :

معنى ذلك أن ما ثبت بالشهادة يعد حجة قبل الكافة، على اعتبار صدورهما من شاهد عدل ليس له مصلحة في النزاع، ولم يوجد ما ينفي دلالتها، كما أن للقاضي سلطة مطلقة في تقديرها وتكوين اعتقاده منها.

بذلك تختلف الشهادة كحجة متعدية عن الإقرار الذي يعد حجة قاصرة على المقر تجاه المقر لصالحه .

رابعاً : الشهادة دليل مقيد :

معنى ذلك أنه لا يجوز الاستعانة بالشهادة في إثبات جميع التصرفات القانونية؛ إذ لا يقبل الإثبات بها إلا في الحالات المحددة تشريعياً ؛ وذلك لأن المشرع قدر احتمال الكذب فيها، فحد من خطرها بحصر حالات إمكان الإثبات يا في حدود ضيقة جماعها أنها حالات لم يجد المشرع من الممكن أو من اللازم تطلب الدليل الكتابي فيها .

يتقيد الإثبات بشهادة الشهود بقيدتين :

اتفاقي	قانوني
- القيد الاتفاقي : فهو وجود اتفاق بين الطرفين على عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجوز إثباته بها ، ووجوب أن يكون الإثبات بالكتابة، فمثل هذا الاتفاق جائز؛ لأن استبعاد الإثبات بالشهادة لا يخالف النظام العام. - القيد القانوني : فهو أن يكون القانون قد منع إثبات الواقعة المراد إثباتها بشهادة الشهود، وأوجب أن يكون إثباتها بالكتابة: - إما بنص خاص كما هو الشأن في الصلح والتحكيم والعمل بالنسبة لصاحب العمل. - إما طبقاً القاعدة عامة.	

قد وضع القانون قاعدتين عامتين تحددان ما لا يجوز إثباته بشهادة الشهود :

الأولى : قاعدة عدم جواز إثبات التصرفات المدنية غير محددة القيمة أو التي تزيد قيمتها عن ألف جنيه بشهادة الشهود.

الثانية : قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة إلا بالكتابة.

شروط قبول الشهادة

يشترط لقبول الشهادة عدة شروط من أهمها ما يلي :

الشرط الأول : أن يتم أداء الشهادة في مجلس القضاء : يشترط في الشهادة من حيث شكلها أن تصدر في مجلس القضاء طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً لذلك.

من ثم لا يعتد بأي شهادة يحصل الإدلاء بها خارج مجلس القضاء، ولو كان ذلك أمام موظف عام مهما علت درجته طالما أنه ليست له ولاية القضاء، بيد أنه لا مانع من أن تستند المحكمة في قضائها على شهادة تم الإدلاء بها في غير مجلس القضاء، وذلك كقرينة قضائية.

كما لا يعتد بالشهادة التي تصدر في مجلس القضاء إذا لم يكن صدورها قد تم وفقاً للإجراءات القانونية، وفي مقدمتها صدور حكم بالإحالة إلى التحقيق متضمناً بيان بالوقائع المراد إثباتها بشهادة الشهود، وتحليف الشاهد اليمين قبل إدلائه بشهادته.

الشرط الثاني : أن يتوافر في موضوع الشهادة ما يشترط توافره في الواقعة المراد إثباتها : يشترط كذلك لقبول الشهادة أن تكون الواقعة المراد إثباتها بشهادة الشهود مستوفية للشروط التي يلزم توافرها في محل الإثبات بوجه عام.

من ثم يجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالشهادة:

- واقعة متنازع عليها، ومحددة
- ذات صلة بالحق المتنازع فيه
- أن تكون منتجة في الإثبات، وأن يكون إثباتها ممكناً مع جوازه .

الهدف من ذلك مراقبة محكمة الموضوع المناسبة لإحالة الدعوى للتحقيق، منعاً من إطالة أمد التقاضي فيما لا فائدة من ورائه في استظهار الحقيقة، بحيث إذا لم تتوافر هذه الشروط قضت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم الآخر برفض إحالة الدعوى للتحقيق.

الشرط الثالث : أن يكون موضوع الشهادة مما يجيز القانون إثباته بالشهادة : يشترط أيضاً لقبول الإثبات بالشهادة أن تكون الواقعة محل الإثبات مما أجاز المشرع إثباتها بشهادة الشهود؛ حيث لا يجوز الاستدلال بشهادة الشهود إلا في الحالات المحددة تشريعاً فقط، وقد حصر المشرع هذه الحالات في نوعين من الحالات : **الأولى :** حالات يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود بحسب الأصل، وهذه الحالات هي :

1. الوقائع المادية.

2. التصرفات التجارية.

3. التصرفات المدنية التي لا تزيد قيمتها على ألف جنيه.

الثانية : حالات يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود استثناءً من وجوب الإثبات بالكتابة، وهذه الحالات هي :

1. وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.

2. وجود مانع يحول دون الحصول على دليل كتابي.

3. فقد السند الكتابي بسبب أجنبي لا يد للدائن فيه.

الشرط الرابع : أن يكون الشاهد أهلاً للشهادة : ولا يكون الشاهد أهلاً للشهادة إلا ببلوغه خمس عشرة سنة كحد أدنى، ومع ذلك يجوز الاستماع إلى أقوال من لم يبلغ هذا السن بغير يمين على سبيل الاستدلال فقط.

من ثم لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه على أقوال هذا الشاهد وحده، وإنما يجوز له فقط أن يسترشد بها لتعزيز أي دليل آخر، وذلك بشرط ألا يقل سنه عند حصول الواقعة المستشهد عليها عن سبع سنوات، والعبرة بسن الشاهد وقت الإدلاء بشهادته لا وقت حصول الواقعة التي يشهد بها .

بالإضافة إلى ذلك لابد أن يكون الشاهد مميزاً ومدركاً وإلا كان ذلك سبباً للرد، وفي ذلك تنص المادة (٨٢) إثبات على أنه: "لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حادثة أو مرض أو لأي سبب آخر".

من ثم لا يجوز سماع شهادة هؤلاء الأشخاص ولو على سبيل الاستدلال، وتقدير عدم تمييز الشاهد مسألة تقديرية لمحكمة الموضوع وشهادة فاقد التمييز فاقدة للحجية، ولو على فاقد تمييز مثله.

الشرط الخامس : أن لا يكون الشاهد ممنوعاً من الشهادة : لقد منع القانون من أداء الشهادة في ثلاث حالات لاعتبارات معينة، وهي : المحافظة على أسرار الدولة ، وأسرار المهنة ، وأسرار الزوجية. هذه الحالات هي :

1. الموظفين والمكلفين بخدمة عامة :

لقد منع المشرع الموظفين والمكلفين بخدمة عامة من الشهادة ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني، ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها، ومع ذلك يجوز لهذه السلطة أن تأذن لهم بالشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

2. أرباب المهن الحرة وأصحاب الصنائع :

منع أيضاً المشرع كل من علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعتة بواقعة أو بمعلومات أن يشهد بها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، إلا في حالة ما إذا كان إفشاء العمل بهذه المعلومات إلى رب المهنة أو الصنعة مقصوداً به ارتكاب جنائية أو جنحة

ومع ذلك يجوز لهم الإدلاء بالشهادة على هذه الوقائع أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم.

3. الأزواج فيما بينهم :

وأخيراً منع المشرع أحد الزوجين أن يشهد بما أبلغه به زوجه الآخر أثناء الزوجة ولو بعد انفصالهما،

إلا أنه استثناءً من ذلك يجوز لأحدهما أن يفضي بما علمه من الآخر في شهادة أمام المحكمة أو القاضي

المنتدب، وذلك في ثلاث حالات :

أ- إذا رضى الزوج الآخر بأن يحل زوجه من واجب الكتمان فيما يتعلق بأسرار الزوجية.

ب- إذا رفع أحد الزوجين دعوى على الآخر أيا كان موضوع الدعوى أو نوعها.

ت- إذا أقيمت على أحد الزوجين دعوى بسبب جنائية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

نطاق الإثبات بشهادة الشهود

- تنص المادة (٦٠) إثبات على أنه: "في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك".
 - تنص المادة (٦٢) على أنه: "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة".
 - تنص المادة (٦٣) على أنه: "يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي : أ- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. ب- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه".
- يتضح من نصوص المواد السابقة أن المشرع المصري قد حصر الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود نوعين من الحالات :
- الأولى : حالات يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود بحسب الأصل.**
- الثانية : حالات يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود استثناء.**
- ينقسم هذا المطلب إلى فرعين:

ما يجوز إثباته بشهادة الشهود بحسب الأصل

يمكن أن نستخلص عن طريق الاستبعاد من نص المادة (٦٠) إثبات الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود بحسب الأصل، وهي :

التصرفات التجارية	الوقائع المادية
التصرفات المدنية التي لا تزيد قيمتها عن ألف جنيه	

- أولاً : الوقائع المادية :** تقسم الوقائع القانونية التي تعتبر مصدراً للحقوق بالنسبة لقواعد الإثبات إلى قسمين :
- تصرف قانوني : وهو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني معين، سواء كان من جانبين كالعقود بصفة عامة، أو من جانب واحد كالإقرار والوصية.
 - واقعة مادية : وهي تتوافر في كل حالة لا ينشأ الأثر القانوني فيها لمجرد اتجاه الإرادة إليه، وهي تشمل :
 - الوقائع الطبيعية، كالوفاة التي يترتب عليها انتقال حقوق المتوفي إلى ورثته.
 - الأفعال المادية التي تصدر من الإنسان، كارتكاب جريمة؛ حيث يترتب على ذلك نشوء حق للمضرور في مطالبة الجاني بالتعويض.

القاعدة في إثبات الوقائع المادية (إلا ما استثناه المشرع بنص خاص وأوجب تسجيله بالكتابة كالميلاد والموت)

جواز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود

- وهذا ما تقتضيه الضرورات العملية؛ حيث إن طبيعة هذه الوقائع لا تقبل استلزام نوع معين من الأدلة، وإلا استحال إثباتها في أغلب الحالات؛ إذ لا تتفق مع إمكان تهيئة الدليل مقدماً على الحقوق التي تنشأ بها، فلا يعقل مثلاً أن يطالب الشخص بدليل كتابي لإثبات الجريمة عندما يطلب التعويض عن الضرر الذي أصابه.
- يلاحظ أن العبرة في تحديد وسائل الإثبات بالواقعة محل الإثبات، دون مراعاة لما يترتب على ثبوت الواقعة المادية من نتائج قانونية، أو بمصدر الحق المطلوب في الدعوي، فإثبات إجازة تصرف قابل للإبطال وهي تصرف قانوني، يمكن أن يتم بشهادة الشهود إذا كانت هذه الإجازة ضمنية تستفاد من أعمال معينة قام بها من له حق التمسك بالبطان، على أساس أن محل الإثبات هو هذه الأعمال
- كذلك يعتبر ادعاء حصول غلط أو إكراه أو تدليس أو استغلال عند التعاقد، أو العلم أو عدم العلم، أو حسن أو سوء النية، من الوقائع المادية التي تثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود.

ثانياً : التصرفات التجارية :

يرجع في تحديد الأعمال التجارية إلى أحكام قانون التجارة، ويعد من أهم هذه الأعمال :

الشراء بقصد البيع أو التأجير، وتأسيس الشركات التجارية وبناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها وشرائها أو بيعها أو تأجيرها أو استئجارها وشراء أدوات أو مواد تموينها، والنقل البحري والنقل الجوي، وعمليات الشحن أو التفريغ.

كذلك عمليات البنوك والجرافة، والوكالة التجارية والسمسرة، وتوريد البضائع والخدمات، والنقل البري، والتأمين على اختلاف أنواعه، إذا مورست على وجه الاحتراف.

القاعدة في التصرفات التجارية جواز إثباتها بشهادة الشهود مطلقاً مهما كانت قيمة التصرف؛ أي حتى ولو زادت قيمته على ألف جنيه، وكذلك إذا لم يكن محدداً القيمة، كما يجوز فيها إثبات ما يخالف أو يجاوز دليل كتابي بشهادة الشهود.

وهو ما أكدت عليه المادة (٦٩) من قانون التجارة بنصها على أنه :

١ - يجوز إثبات الالتزامات التجارية أي كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك.
٢ - فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق".

يرجع السبب في إباحة الإثبات بشهادة الشهود في التصرفات التجارية أي كانت قيمة التصرف، إلى :

- ما تقتضيه طبيعة المعاملات التجارية من السرعة.
- ما تستلزمه من التيسير والبساطة.
- ما تستغرقه من وقت قصير في تنفيذها، مما ييسر الإثبات فيها بشهادة الشهود.
- بيد أن المشرع قد استثنى بعض التصرفات التجارية من ذلك، واستلزم أن يكون الإثبات فيها بالكتابة :
- إما لأن هذه التصرفات لا يمكن أن توجد إلا كتابة، كما هو الشأن في الأوراق التجارية.
- وإما لأنها تنطوي على أهمية خاصة فضلاً على أنها تستغرق وقتاً طويلاً،
- كعقود الشركات التجارية، وعقود بيع السفن وإيجارها، وعقود النقل البحري، والقروض البحرية .

ثالثاً : التصرفات المدنية التي لا تزيد قيمتها عن ألف جنيه :

أجاز كذلك المشرع إثبات التصرفات المدنية التي لا تجاوز قيمتها ألف جنيه بالشهادة كقاعدة عامة رغبة منه في التيسير على المتعاملين؛ ولذلك تعتبر هذه القاعدة موضوعاً لمصلحة المتعاملين أنفسهم، وغير متعلقة بالنظام العام، ومن ثم يجوز الاتفاق على مخالفتها؛ فإذا اتفق المتعاقدان على أن الإثبات فيما بينهما لا يكون إلا بالكتابة حيث يجيز القانون الإثبات بالشهادة، صح اتفاقهما ووجب العمل به.
بيد أنه يرد على قاعدة جواز الإثبات بشهادة الشهود في التصرفات المدنية التي لا تجاوز قيمتها ألف جنيه استثناءان، هما :

الاستثناء الأول : إثبات التصرفات المدنية التي يوجب القانون إثباتها بالكتابة ولو لم تجاوز قيمتها ألف جنيه، كعقد الكفالة ، وعقد الصلح ، وعقد الشركة.

الاستثناء الثاني : وجوب إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي بالكتابة ولو لم تزد قيمة التصرف عن ألف جنيه؛ إذ تنص المادة (٦١) إثبات على أنه: "لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه: (أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي".

يمثل هذا النص قيد أو استثناء على قاعدة جواز إثبات التصرفات المدنية التي لا تجاوز قيمتها ألف جنيه؛ حيث أوجب إثبات هذه التصرفات بالكتابة إذا كانت تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
الحكمة من هذا الاستثناء هي وجوب المساواة بين الخصوم في الإثبات، فما يثبتته خصم بالكتابة لا يجوز للآخر أن ينقضه بشهادة الشهود؛ حيث أن الكتابة أقوى دلالة من الشهادة التي يحوم الشك حول صدقها، بالإضافة إلى أن حرص المتعاقدين على كتابة التصرف رغم أن قيمته لا تتجاوز نصاب الإثبات بالشهادة، دليل على رغبتهم في الاحتكام للكتابة كوسيلة لإثبات التصرف واستبعاد الإثبات بالشهادة، بصرف النظر عن قيمة التصرف.

يشترط لانطباق هذا الاستثناء ثلاثة شروط :

الشرط الأول : وجود دليل كتابي : فيشترط لتطبيق هذا الاستثناء وجود ورقة مكتوبة تعتبر دليلاً كاملاً، كالأوراق الرسمية، أو الأوراق العرفية المعدة للإثبات، أو الرسائل الموقع عليها.

من ثم لا يتحقق هذا الشرط إذا كنا بصدد دليل كتابي غير كامل، وهو الأوراق التي لم تعد أصلاً للإثبات، كالدفاتر التجارية والأوراق المنزلية والتأشير على سند الدين، فإنها لا تخضع لحكم هذا القيد، فيجوز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها بشهادة الشهود.

يجب أن يكون الحصول على الدليل الكتابي قد تم بطريق مشروع، فمن يستولى مثلاً على الدليل الكتابي دون علم الطرف الآخر ورضاه، لا يجوز له أن يتمسك بعدم جواز إثبات عكس ما اشتملت عليه الكتابة إلا بالكتابة. تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه : "لا يجوز لمن حصل على ورقة عرفية بطريق غير مشروع الاحتجاج بالدليل المستمد من هذه الورقة، وبالتالي لا يقبل منه التمسك بعدم جواز إثبات عكس ما اشتملت عليه إلا بالكتابة".

الشرط الثاني : أن يكون التصرف الثابت بهذا الدليل مدنياً :

يشترط كذلك أن يكون التصرف الثابت بالكتابة تصرفاً مدنياً، فإذا كان تجارياً لم ينطبق عليه هذا القيد، ومن ثم يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز الكتابة في التصرفات القانونية التجارية أي كانت قيمتها بشهادة الشهود. وهو ما قننته المادة (٦٩) من قانون التجارة على أنه : "٢ - فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق".

الشرط الثالث : أن يكون المراد إثباته مخالفاً أو مجاوزاً لما اشتملت عليه الكتابة : فلا يمنع من الإثبات

بشهادة الشهود في التصرفات المدنية التي لا تجاوز قيمتها ألف جنيه، إلا إذا كان موضوع هذا الإثبات أمراً يخالف أو يجاوز ما ثبت بالكتابة؛ أي إذا كان أمراً يعتبر تكديفاً أو تعديلاً للمكتوب أو إضافة إليه فمثلاً إذا ذكر في عقد البيع أن الثمن خمسمائة جنيه، ولم يذكر شيئاً عن سريان فوائد عليه، ولا عن مكان الوفاء به، ففي هذه الحالة لا تقبل شهادة الشهود في إثبات أن حقيقة الثمن أربعمائة جنيه، أو على وجود اتفاق شفوي على سريان فوائد أو على وجود اتفاق على أن يكون الوفاء في غير المكان الذي تعينه القواعد العامة. أما إذا كان المراد إثباته لا ينطوي على تكذيب أو تعديل لما هو ثابت بالكتابة، فإن إثباته لا يعد إثباتاً لما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي، ولو كان يترتب عليه عكس الأثر المترتب على ما أثبتته الكتابة، فإثبات الوفاء بالدين أو انقضائه بالتقادم أو وجود عيب من عيوب الإرادة مثلاً لا يعد إثباتاً لما يخالف أو يجاوز ما هو ثابت بالكتابة؛ لأنه لا ينطوي على تكذيب أو تعديل لما اشتملت عليه الكتابة.

قواعد تقدير قيمة التصرف القانوني : لقد وضع المشرع عدة قواعد يجب اتباعها في تقدير قيمة التصرف

القانوني، وذلك لتحديد مدى جواز إثباته بشهادة الشهود، ويمكن تحديد هذه القواعد على النحو التالي :

أولاً : العبرة بقيمة الالتزام وقت صدور التصرف لا وقت المطالبة به :

إذ تنص المادة (2/60) إثبات على أنه : "ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على ألف جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل". بناءً على هذا النص، ينظر في تقدير قيمة التصرف إلى وقت صدوره دون نظر إلى ما يطرأ عليه من زيادة أو نقص، فإذا كان التصرف يزيد في قيمته وقت صدوره عن ألف جنيه، وجب الإثبات بالكتابة ولو كانت القيمة أقل من ذلك وقت رفع الدعوى

وعلى العكس من ذلك إذا كانت قيمة التصرف وقت صدوره لا تزيد عن ألف جنيه، جاز الإثبات بشهادة الشهود حتى ولو زادت هذه القيمة على هذا القدر وقت المطالبة به بسبب ضم الفوائد والملحقات.

ثانياً : العبرة في تقدير القيمة بوحدة مصدر الطلبات في الدعوى :

إذ تنص المادة (3/60) إثبات على أنه : "وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على ألف جنيه، ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة".

فالطلبات المتعددة في دعوى واحدة لا تجمع دائماً إلى بعضها لتحديد وسيلة إثباتها، بحيث إذا زاد مجموعها على ألف جنيه وجب إثباتها بالكتابة؛ إذ العبرة بوحدة مصدر هذه الطلبات أو تعدده :

- فإن كانت ناشئة عن تصرف واحد جمعت لتقدير جواز إثباتها بشهادة الشهود، كمن يلتزم بثمن عدة أشياء ابتاعها في صفقة واحدة، فإن العبرة بقيمتها كلها، ومن ثم وجب الإثبات بالكتابة إذا زادت القيمة على ألف جنيه.
- أما إن كانت تستند إلى عدة تصرفات فإن كل تصرف يقوم مستقلاً في حساب نصاب الإثبات، كمن يلتزم بثلاث مبالغ نقدية ناشئة عن عقدين مختلفين في الطبيعة (بيع وقرض أو بيع وإيجار)، أو ناشئة عن عقدين من طبيعة واحدة ولكنهما مستقلين، فإن العبرة في هذه الحالة يكون بقيمة الحقوق الناشئة عن كل منها، ومن ثم يجوز الإثبات بشهادة الشهود ما دام كل منها لا يزيد في قيمته على ألف جنيه، حتى ولو زادت قيمتها مجتمعة على هذا القدر.

ثالثاً: العبرة في الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي :

إذ تنص المادة (60 / 4) إثبات على أنه: "وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئياً بقيمة الالتزام الأصلي".
على ذلك إذا كانت قيمة الالتزام الأصلي تجاوز ألف جنيه، فإنه لا يجوز إثبات الوفاء الجزئي بشهادة الشهود حتى ولو كان ما أوفى به المدين يقل عن هذا القدر؛ وذلك حتى لا يتحايل المدين بدين تزيد قيمته على ألف جنيه على قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة في هذه الحالة، بأن يدعي أن الوفاء كان على أجزاء متعددة يقل كل منها على ألف جنيه متخلص بذلك من وجوب الإثبات بالكتابة.

رابعاً: العبرة بالقيمة الإجمالية للالتزام وليس بقيمة المطالبة الجزئية منه :

إذ تنص المادة (٦١) إثبات على أنه: "لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه: (ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة".

مقتضى ذلك أن العبرة في تقدير قيمة المدعى به هي بقيمة التصرف بأكمله، وليس بقيمة ما كان محلاً للمطالبة القضائية، سواء كانت هذه المطالبة تمثل مطالبة بجزء منه أو بقسط من أقساطه أو بالجزء المتبقي منه، فالمطالبة بجزء من حق تجب الكتابة لإثباته، لا تعفي من الإثبات بالكتابة ولو كان الجزء المطلوب لا يزيد قيمته على ألف جنيه.

الهدف من ذلك منع تحايل الدائن على التنظيم التشريعي لنطاق الدليل الكتابي في الإثبات من خلال تبعض مطالبته بالدين على دفعات متعددة تدخل كل منها في حدود نصاب الإثبات بشهادة الشهود، رغم أن القيمة الإجمالية للالتزام تتجاوز نصاب الإثبات بها.

خامساً: العبرة بالقيمة الأصلية للطلب القضائي :

إن تنص المادة (٦١) إثبات على أنه: "لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على ألف جنيه: (ج) إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألف جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد عن هذه القيمة".
مفاد هذا النص أن المشرع قد اتخذ من رفع المدعي دعواه بأكثر من ألف جنيه، قرينة على أن قيمة حقه تزيد فعلاً عن ألف جنيه، وأن تعديل طلبه بالإنقاص عن هذا القدر ما قصد منه إلا الهرب من قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة؛ لذا يظل المدعي مطالباً بالدليل الكتابي كما لو لم يخفض طلباته.

ما يجوز إثباته بشهادة الشهود استثناء

بالإضافة إلى الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود بحسب الأصل توجد عدة حالات أخرى يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود استثناء، ومعنى ذلك أن هذه الحالات الأصل فيها الإثبات بالكتابة، ولكن من قبيل الاستثناء أجاز إثباتها بشهادة الشهود، وهذه الحالات ذكرتها المادتين (٦٢، ٦٣) إثبات، وهي :

أولاً : وجود مبدأ ثبوت بالكتابة | **ثانياً : وجود مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي**

ثالثاً : فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه

أولاً: وجود مبدأ ثبوت بالكتابة :

تنص المادة (٦٢) إثبات على أنه: " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ".

المقصود بمبدأ الثبوت بالكتابة وفقاً للنص السابق : " هو كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ".

فالكتابة الصادرة من الخصم والتي يستفاد منها مبدأ الثبوت بالكتابة لا ترقى إلى مستوى الدليل الكتابي الكامل

ولا تقوم مقامه، بحيث لا يصح الاستناد إليها بصفة منفردة كدليل إثبات فيما كان يجب إثباته بالكتابة، ولكن لما كانت تحمل على الاعتقاد بأن التصرف المدعى به قريب الاحتمال، فإنه يقبل الاستناد إليها كعنصر من عناصر الإثبات معززة بشهادة الشهود لإثبات ما لم يكن يصح إثباته إلا بالكتابة.

يترتب على هذا الاستثناء أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود، إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة في التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على ألف جنيه، وفي إثبات ما يخالف أو يجاوز الكتابة، وكذلك في التصرفات التي يتطلب المشرع الكتابة لإثباتها دون اعتبار لقيمة التصرف كعقد الصلح، وذلك لأن المشرع اعتبر مبدأ الثبوت بالكتابة إذا أيدته الشهادة مساوياً للكتابة الكاملة .

شروط مبدأ الثبوت بالكتابة :

يتضح من نص المادة (6٢) إثبات أنه يشترط لكي نكون بصدد مبدأ ثبوت بالكتابة توافر ثلاثة شروط، وهي:

الشرط الأول : وجود كتابة :

لا بد في مبدأ الثبوت بالكتابة من وجود ورقة مكتوبة، وكل كتابة تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة، أيا كان شكلها أو الغرض منها، كالسند غير الموقع، والخطاب أو المذكرة الخاصة، والدفتر المنزلي، والإيصال، وصورة المحرر الرسمي أو العرفي، أو الأقوال المدونة في محضر التحقيق، وغير ذلك ما لم تكن دليلاً كاملاً بالنسبة لموضوع الدعوى، ومن ثم لا يكفي لوجود هذا المبدأ الأقوال الشفوية أو الأعمال المادية المحضة.

يجب أن تكون الورقة التي تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة مقدمة في الدعوى أو على الأقل معترفاً بوجودها ممن تنسب إليه، وإلا فلا يستطيع من يتمسك بها (عند الإنكار) أن يقيم الدليل على سبق وجودها وفقدانها منه بشهادة الشهود.

الشرط الثاني : صدور الكتابة من الخصم المدعي عليه :

يجب كذلك لاعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة أن تكون صادرة من الخصم المدعي عليه، بأن تكون :

- يخطه أو موقعة منه
- أو تكون صادرة ممن ينوب عنه نيابة قانونية كالوصي والقيم، أو نيابة اتفاقية كالوكيل، بشرط أن تكون الورقة قد صدرت من النائب في حدود نيابته
- أو تكون صادرة من سلفه (المورث)، فإذا لم تكن الورقة صادرة من المدعي عليه أو من نائبه أو من سلفه، فلا يتحقق هذا الشرط أياً كانت الصلة التي تربط المدعي عليه بمن صدرت منه الورقة، كما لو كان ابناً أو زوجاً مثلاً.

الأصل أن الورقة تعتبر صادرة من المدعي عليه إذا كانت موقعة منه أو ممن يمثله، أو مكتوبة بخطه أو بخط من يمثله، إلا أن هناك بعض الأوراق التي يمكن اعتبارها صادرة من الشخص رغم أنها ليست موقعة منه أو ممن يمثله ولا مكتوبة بخطه أو بخط من يمثله، كمحاضر التحقيق وحاضر الجلسات؛ إذ يعتبر ما ورد فيها على لسان الخصم صادرة منه، ومن ثم تعد مبدأ ثبوت بالكتابة ولو لم يوقعها، بشرط ألا تصل إلى درجة الإقرار.

الشرط الثالث : جعل الأمر المدعى به قريب الاحتمال:

يشترط أيضاً لاعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال أي أن كون من شأن الورقة جعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول، وأن هناك مظنة على صحتها، وبذلك تعتبر دليلاً كتابياً ناقصاً يمكن تكملته بشهادة الشهود

- فالرسالة التي يذكر فيها المدين أنه مدين دون أن يذكر مقدار الدين تجعل مديونته واقعة قريبة الاحتمال
- وكذلك محضر جرد التركة الذي يتم أمام الدائن دون أن يذكر فيه الدين يعتبر مبدأً ثبوت بالنسبة للوفاء بالدين؛ لأنه لو كان الدين باقياً في ذمة المورث (المدين) لما خلا منه محضر الجرد.
- وتقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأً ثبوت بالكتابة تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال، يعد مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض.

ثانياً: وجود مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي:

تنص المادة (٦٣) إثبات على أنه: "يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي: (أ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي".

مؤدى هذا النص أنه قد توجد ظروف تحول بين الشخص وبين الحصول على دليل كتابي، فأجاز المشرع في هذه الحالة الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة؛ وذلك لأن وجوب الإثبات بالكتابة يفترض إمكان الحصول على الدليل الكتابي، فإذا حالت ظروف خاصة دون ذلك تحتم الاستثناء؛ إذ لا قبل لأحد بالمستحيل.

يجوز الإثبات بشهادة الشهود في هذا الاستثناء في التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على ألف جنيه، وفي إثبات ما يخالف أو يجاوز الكتابة، بل وفي التصرفات التي يتطلب المشرع الكتابة لإثباتها دون اعتبار لقيمة التصرف كعقد الصلح والكفالة

إن شهادة الشهود في تلك الأحوال لا تكمل الدليل الكتابي (كما هو الشأن في مبدأ الثبوت بالكتابة) ولكنها تحل محله؛ لاستحالة الحصول عليه.

يقصد بالمانع من الحصول على الكتابة : المانع الذي ينشأ عنه استحالة الحصول على كتابة وقت التعاقد استحالة نسبية عارضة؛ أي استحالة مقصورة على شخص معين، وراجعة إلى الظروف الخاصة التي تم فيها التعاقد.

قد يكون المانع مادياً أو أدبياً :

1. المانع المادي : وهو المانع الذي ينشأ عن الظروف الخارجية لإبرام التصرف، والتي لم تسمح بالحصول على الدليل الكتابي.

فلاستحالة المادية تفترض أن التصرف القانوني نشأ في ظروف لم يكن لذي الشأن فيها فسحة من الوقت أو وسيلة للحصول على دليل كتابي، ومن قبيل ذلك الوديعة الاضطرارية التي تحدث في عجلة لدفع خطر داهم كحريق أو غرق، ويلحق بها كافة التصرفات التي تنشأ عند الكوارث أو الحوادث المفاجئة أو الحرائق أو النكبات.

2. المانع الأدبي : وهو الذي يرجع إلى اعتبارات وظروف نفسية تقوم في الوقت الذي يتم فيه التصرف، فتمنع الشخص من الحصول على دليل كتابي، وهذا ما يتحقق إذا كانت تقوم بين الطرفين صلة خاصة، أو جرت العادات المتعارف عليها بين الناس على عدم السماح لأحد المتعاقدين أن يطلب كتابة من الطرف الآخر.

من قبيل هذه الموانع الأدبية : وجود صلة قرابة أو مصاهرة أو خطبة أو زوجية بين طرفي التصرف، أو صلة الطبيب بمرضيه، أو الخادم بسيده.

وأياً كان المانع (مادياً أو أدبياً) فإن تقديره موكل إلى قاضي الموضوع، وهو لا يخضع في ذلك إلى رقابة محكمة النقض، بشرط أن يسبب تقديره، بأن يورد في أسباب حكمه الواقعة التي اعتبرها مانعاً، ويبين لماذا يضي عليها هذا الاعتبار.

ثالثاً: فقد الدائن سند الكتبي لسبب أجنبي لا يد له فيه :

تنص المادة (٦٣) إثبات على أنه: "يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي: (ب) إذا فقد الدائن سنده الكتبي بسبب أجنبي لا يد له فيه".

يفترض هذا الاستثناء أن الدائن قد حصل على الدليل الكتابي الذي يقضي به القانون، ولكنه بعد حصوله على هذا الدليل فقد سبب أجنبي لا يد له فيه، فكانت الضرورة هنا أكثر وضوحاً من الاستثناءين السابقين ؛ وذلك لأن الدليل الكتابي قد وجد فعلاً ولكنه فقد من غير تقصير من الدائن، لذا أجاز المشرع أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابي لإثبات:

1. التصرفات التي تزيد قيمتها على ألف جنيه.
2. ما يخالف الكتابة أو يجاوزها.
3. أي عقد يشترط القانون أن يكون إثباته بالكتابة ولو لم تجاوز قيمته ألف جنيه.
4. أي عقد شكلي كالهبة والرهن الرسمي.

بذلك فإن نطاق تطبيق هذا الاستثناء أوسع من نطاق الاستثناءين السابقين؛ حيث إن توافرها لا يجيز إثبات العقد الشكلي بشهادة الشهود، ويرجع ذلك إلى أن الدليل الكتابي هنا سبق وأن وجد، فالمسألة ليست امتناع تحصيل هذا الدليل بل امتناع تقديمه.

يلزم لقيام الاستثناء في هذه الحالة توافر شرطان:

الشرط الأول: سبق وجود سند قانوني : فيجب على المدعي أن يثبت سبق وجود سند كتابي، ومضمون هذا السند، وتوافر الشروط الخاصة التي تلزم فيه إن كانت له شروط خاصة، وللمدعي أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود؛ لأن سبق وجود السند واقعة مادية.

يقصد بالسند الواجب إثبات وجوده الدليل الكتابي الكامل، فلا يكفي أن يثبت المدعي سبق وجود ورقة تعتبر بداية ثبوت بالكتابة؛ وذلك لأن المشرع لا يحمي المدعي إلا إذا كان لم يقصر على أي صورة، وعدم حصوله على سند كتابي كامل يعتبر بمثابة التقصير من جانبه.

الشرط الثاني: فقد السند بسبب أجنبي : يجب بالإضافة إلى إثبات سبق وجود الدليل الكتابي أن يثبت المدعي أن فقد هذا السند كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

يعتبر السبب في عجز المدعي عن تقديم الدليل الكتابي سبباً أجنبياً يترتب عليه جواز الإثبات بشهادة الشهود، إذا كان راجعاً إلى :

- قوة قاهرة ، كحريق أو فيضان
- أو إلى فعل المدعي عليه ، كما لو اختلسه أو انتزعه من المدعي بالقوة أو بالحيلة
- أو إلى فعل الغير ، كما لو سلم المدعي السند إلى محاميه أو إلى المحكمة في قضية سابقة ففقد من المحامي أو من المحكمة.

من ثم لا يمكن للمدعي أن يتمسك بهذا الاستثناء إذا كان فقد السند راجعاً إلى فعل المدعي أو إلى إهماله أو إلى فعل أحد ممن يعتبر هو مسئولاً عنهم، كأن يكون المدعي قد مزق السند ضمن أوراق أخرى مستغني عنها، أو تركه على مكتبه فألقاه أو أتلفه خادمه.

وللمدعي أن يثبت أن فقد السند كان بسبب أجنبي ولم يكن بفعله بكافة طرق الإثبات؛ لأن إثبات السبب الأجنبي إثبات الواقعة مادية.